

第4節 違法性の意識と法律の錯誤

刑法
No122

H19-20

(配点：3)

月 日

月 日

次の【見解】ⅠないしⅢに従って、後記の【記述】アないしウについて正誤を検討した場合、後記1から5までのうち、正しいものはどれか。

【見 解】

- Ⅰ. 行為者が正当防衛に当たる事実があると誤信した場合には故意が否定され、過失犯が成立し得るにとどまる。違法性の意識の有無は故意の成立とは無関係であるが、違法性の意識の可能性がなければ、責任を肯定することはできない。
- Ⅱ. 行為者が正当防衛に当たる事実があると誤信した場合には故意が否定され、過失犯が成立し得るにとどまる。違法性の意識は故意の要件であり、違法性の意識が認められない場合には故意が否定される。
- Ⅲ. 行為者が正当防衛に当たる事実があると誤信した場合であっても、故意は否定されないが、誤信についてやむを得ない事情があった場合には責任が否定される。違法性の意識の有無は故意の成立とは無関係であるが、違法性の意識の可能性がなければ、責任を肯定することはできない。

【記 述】

- ア. 行為者は、実際には正当防衛に該当する事実が存在しないのに、これが存在すると誤信したこの誤信にやむを得ない理由があった場合、行為者に犯罪は成立しない。
- イ. 行為者は、実際には正当防衛に該当する事実が存在しないのに、これが存在すると誤信した。この誤信が不注意によるものであった場合、行為者に故意犯は成立せず、過失犯が成立し得る。
- ウ. 行為者は、事実に関する誤信はなかったものの、正当防衛の成立要件について誤解していたため、正当防衛が成立しないのに、成立すると誤信した。この誤信にやむを得ない理由があったとはいえない場合、行為者に故意犯は成立しない。

1. 【見解】Ⅰに従うと、【記述】アは誤りである。
2. 【見解】Ⅰに従うと、【記述】ウは正しい。
3. 【見解】Ⅱに従うと、【記述】イは誤りである。
4. 【見解】Ⅱに従うと、【記述】ウは正しい。
5. 【見解】Ⅲに従うと、【記述】アは誤りである。

正当防衛の要件にあたる事実がないのにその事実が存在すると誤信して行われる反撃行為である誤想防衛についての学説は、事実の錯誤ないし独自の錯誤として故意を阻却し、その錯誤について過失があるときは過失犯が成立すると解する立場（①説）、誤想防衛においても行為者の意思は構成要件の結果の惹起に向けられており、いわゆる規範の問題に直面しているのであるから、誤想防衛は違法性の錯誤として故意を阻却しないと解する立場（②説）に分かれている。本問の見解Ⅰ・Ⅱは①説、Ⅲは②説をとる。

次に、故意責任を認めるために常に違法性の意識が必要となるかについて学説は、故意責任の特質は自己の行為が法律上許されないことを認識しつつ敢えて行為を決意する直接的な反規範的意思活動ないし人格態度にあるとする違法性の意識必要説（A説）、故意の要件として犯罪事実の認識があれば足りるとする違法性の意識不要説（B説）、違法性の意識自体は必要ではないが、違法性の意識の可能性は故意の要件として必要であるとする違法性の意識の可能性必要説（C説）、違法性の意識の可能性は、故意とは独立の故意・過失に共通する責任要素であり、構成要件該当事実ないし犯罪事実を認識しそれを実現する意思がある以上、違法性の意識を喚起し反対動機を形成すべき現実の機会があったのにあえて行為に及んだ点において非難可能性があるとする責任説（D説）に分かれる。本問の見解Ⅰ・ⅢはD説、ⅡはA説をとる。

以上を前提に各記述について検討する。

1 誤っている

見解Ⅰに従うと、実際には正当防衛に該当する事実が存在しないのに存在すると誤信した場合、故意が否定され、過失犯が成立し得るにとどまることとなる。そこで、過失責任を問うことができるかについて検討すると、見解Ⅰは責任を肯定するためには違法性の意識の可能性を要求している。そして行為者の誤信にやむを得ない理由がある場合、違法性の意識の可能性は否定され犯罪は成立しない。よって見解Ⅰに従うと、責任が否定されることとなる。よって、見解Ⅰに従った場合、行為者に犯罪は成立しないから、記述アは正しい。したがって、これを誤りであるとしている本記述は誤っている。

2 誤っている

見解Ⅰに従うと、記述ウのように、行為者が法律の成立要件について誤解していたに過ぎず、事実に関する誤信がない場合には、見解Ⅰにいう「行為者が正当防衛に当たる事実があると誤信した場合」にあてはまらないから、故意は否定されない。また、記述ウでは誤信にやむを得ない理由があったとはいえないとされているから、違法性の意識の可能性は存在し、責任も否定されない。以上より、見解Ⅰに従った場合、行為者に故意犯が成立するから、記述ウは誤りである。したがって、これを正しいとしている本記述は誤っている。

3 誤っている

見解Ⅱに従うと、記述イのように、実際には正当防衛に該当する事実が存在しないのに存在すると誤信した場合には、故意が否定されるから故意犯は成立せず、過失犯が成立し得るにとどまることとなる。なお、すでに故意が否定された以上、故意の成否にのみ関係する見解Ⅱ後段は問題とならない。次に、過失犯の成否について検討すると、記述イでは誤信が不注意によるものであったのだから、過失が認められる可能性があり、過失犯が成立し得る。よって、見解Ⅱに従った場合、行

為者に故意犯は成立しないが過失犯が成立し得るから、記述イは正しい。したがって、これを誤りであるとしている本記述は誤っている。

4 正しい

見解Ⅱに従うと、実際には正当防衛に該当する事実が存在しないのに存在すると誤信した場合、故意が否定され、過失犯が成立し得るにとどまることとなる。しかし、記述ウにおいて行為者は事実に関する誤信をしていたわけではなく、正当防衛の成立要件について誤解していたためあてはめの錯誤に陥ったに過ぎない。この錯誤は違法性の錯誤にすぎず、見解Ⅱに立ったとしても故意を否定しない。しかし、見解Ⅱは故意の要件として違法性の意識を要求しているところ、行為者は自己に正当防衛が成立すると誤信しており、違法性の意識が欠けている。よって、見解Ⅱに従った場合、行為者に故意犯は成立しないから記述ウは正しい。したがって、これを正しいとしている本記述は正しい。

5 誤っている

見解Ⅲに従うと、実際には正当防衛に該当する事実が存在しないのに存在すると誤信した場合でも故意は否定されないが、誤信についてやむを得ない事情があった場合には責任が否定されることとなる。記述アは、行為者は実際には正当防衛に該当する事実がないのにこれが存在すると誤信している。この場合、見解Ⅲからすると故意は否定されない。しかし、この誤信にやむを得ない理由があった場合、違法性の意識の可能性が否定されるから、見解Ⅲに従うと責任が否定される。よって、見解Ⅲに従った場合、行為者に犯罪は成立しないから記述アは正しい。したがって、これを誤りであるとしている本記述は誤っている。